

< 사례문제 1의 해결>

1. 문제의 소재

사안에서는 먼저 갑의 대여사실과 관련하여 자유심증주의의 한 내용인 증거공통원칙에 따라 피고의 증인신청에 따라 법원에 현출된 병의 증언에 의하여 대여사실을 인정할 수 있는 것인지가 문제 되고, 을의 변제사실과 관련하여 변제사실이 변론주의의 주요 내용 중 하나인 사실의 주장책임의 적용대상이 되는 주요사실에 해당되는 것인지와 주요사실에 해당된다면 사실자료와 증거자료는 준별되어야 한다는 주장책임의 내용에 따라 피고의 변제사실에 관한 주장이 없으므로 법원은 병의 증언(증거자료)에 의하여 변제 사실을 인정해서는 안 되는 것인지 그렇다면 판례가 인정하는 간접적 주장이론을 본 사안에 적용할 수는 있는 것인지 등이 문제된다.

2. 대여사실의 인정여부

(1) 자유심증주의와 증거공통의 원칙

자유심증주의란 법원이 형식적인 증거법칙의 제약을 받지 않고서 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과인 증거자료를 참작하여 그에 따라 형성된 자유로운 심증으로 재판의 기초가 되는 주장사실의 진위여부(眞僞與否)를 판단한다는 원칙을 말한다. (민사소송법 제202조). 이에 따라 법원은 증거방법이나 증거능력에 관한 제한을 받지 않을 뿐만 아니라 당사자가 제출한 증거에 대한 증거력평가를 자유롭게 할 수 있기 때문에 증거에 대한 증거조사의 결과(증거자료)를 증거제출자에게 유리하게 평가(판단)할 수도 있고 즉, 유리한 사실의 인정자료로 삼을 수도 있고 반대로 상대방의 원용에 관계 없이 그 제출자에게 불리하게도 평가할 수 있게, 즉 불리한 사실의 인정자료로도 삼을 수 있게 되는데 이를 증거공통의 원칙이라고 한다.¹⁾

(2) 사안의 경우

갑은 청구원인사실로서 대여사실을 주장하고 있고 을의 신청에 따라 증인으로 채택된 병이 을에게 불리한 대여사실을 증언하였는데, 이러한 경우 법원은 증거공통의 원칙에 따라 증거조사의 결과인 을의 증언에 의하여 을에게 불리한 사실이라 할 수 있는 대여사실을 인정할 수 있다.

3. 변제사실의 인정여부

1) 증거공통의 원칙은 공동소송인 사이에서도 인정되는데, 공동소송의 경우에 공동소송인 1인이 제출한 증거로부터 얻은 증거자료가 다른 공동소송인에게도 공통으로 증거자료가 된다. 다만, 공동소송인 사이에 이해관계가 서로 상반되는 경우에는 그에 대한 원용이 없는 한 위 원칙은 적용되지 않는 것으로 보아야 한다.

(1) 변론주의의 의의와 기능

변론주의란 사실과 증거의 수집·제출책임을 당사자에게 맡기고 법원은 당사자가 수집하여 제출한 소송자료만을 판결의 기초로 삼아야 한다는 입장이다. 이는 사적 자치의 원칙을 소송법상 반영한 것임과 동시에 이에 의할 때 진실발견이 용이해 지고 절차보장이 충실하게 됨으로써 공평한 재판이 보장된다는 점 등이 그 인정 근거로 설명되고 있고, 우리 민사소송절차를 관류하는 대원칙으로서 당사자에 대한 불의의 타격 즉 예상외 재판을 방지하는 기능을 수행한다. 변론주의는 사실의 주장책임, 자백의 구속력, 증거의 제출책임(직권증거조사 금지)등 세 가지 명제를 주요내용으로 하고 있는데, 사안에서는 변제사실이 주장책임을 적용대상이 되는 것인지가 문제된다.

(2) 사실의 주장책임

1) 의의

권리의 발생·변경·소멸 즉 권리의 변동이라는 법률효과를 발생시키는 원인이 되는 실체법상의 구성요건사실인 주요사실은 당사자가 변론에서 주장하여만 법원이 판결의 기초로 삼을 수 있고 주장하지 아니하면 판결의 기초로 삼을 수 없다. 따라서 당사자가 자기에게 유리한 사실을 주장하지 아니하면 그 사실은 없는 것으로 취급되어 불이익한 판단을 받게 되는데 이를 주장책임이라고 한다. 이와 같이 주장책임을 적용대상이 되는 사실은 주요사실로서 경험법칙 등의 도움을 받아 주요사실의 존부를 추인하게 하는 사실인 간접사실과 증거능력이나 증거가치에 관한 사실인 보조사실은 그 적용대상이 아니다.

2) 주장책임을 분배 및 사실자료와 증거자료의 준별

통설, 판례의 입장인 법률요건분류설에 따라 원고 또는 피고가 유리한 판결을 받기 위해서 원고는 청구원인사실(권리발생사실)을, 피고는 항변사실(권리장애사실, 권리멸각사실, 권리저지사실)을 주장하여야 하므로 원, 피고는 각각 그에 따른 주장책임을 부담하게 된다. 사안에 있어서와 같이 같이 주장한 대역사실에 대한 관계에서 변제사실은 항변사실(권리멸각사실)로서 주요사실에 해당하므로 을이 그 사실을 주장하지 않은 이상 법원은 증인의 증언이나 그 밖의 증거자료에 의하여 변제사실을 알았다 하더라도 이를 판결의 기초로 삼아서는 안 된다. 왜냐하면 변론주의에 의해 심리되는 민사소송사건에서 사실자료는 증거자료와 엄격하게 구별되어야 하기 때문이다,²⁾

3) 간접적 주장이론

2) 대법원 198.8.11. 선고 81다262,263

① 위와 같이 사실자료와 증거자료를 준별하는 입장을 강조하게 되면 때로는 부당한 결과가 생기게 되는데 이러한 경우에 대비하여 대법원은 간접적 주장이론을 인정하고 있다. 이는 당사자가 변론에서 직접적으로 주요사실을 주장하지는 않았다 하더라도 법원에 현출된 소송자료나 증거자료를 통해 일정한 경우 당사자가 그 사실을 주장한 것으로 의제하는 것을 말한다. 예컨대 당사자가 법원에 서증을 제출하면서 그 증명취지를 진술함으로써 서증에 기재된 사실을 주장한 경우나 당사자가 감정서나 서증을 이익으로 원용한 경우등에 있어서 주요사실에 관한 주장을 한 것으로 보는 것이다.³⁾

② 사안의 경우

을이 변론에서 변제사실을 주장한 바가 없으므로 법원은 이를 판결의 기초로 삼을 수 없음이 원칙이다.¹⁾ 그러나 일반적으로 당사자는 증거신청을 함에 있어서 증명할 사실과 특정의 증거방법 그리고 증명의 취지를 구체적으로 밝혀야 하는 것으로 되어 있으므로(민사소송법 제289조 제1항, 제308조, 민사소송규칙 제74조), 을은 변론에서 갑으로부터 돈을 대여받은 사실을 부인하고 병을 증인으로 신청함에 있어서 갑에게 변제한 사실을 증명하기 위한 것이라고 그 증명의 취지를 진술하면서 병을 증인으로 신청하였을 것으로 보이므로 간접적 주장이론을 적용하여 을이 변제사실을 주장한 것으로 볼 수 있을 것이다. 설사 그렇지 않았다 하더라도 갑으로부터의 대여사실을 전부 부인한 을의 입장에서 보면 그 대여사실에 대한 증명책임이 갑에게 있기 때문에 을은 증거신청을 할 필요가 없었음에도 불구하고 을이 구지 증거(증인)신청을 한 사실에 비추어 볼 때 을이 증인신청을 한 취지는 변제사실을 증명하기 위함이었던 것으로 추정할 수도 있을 것이므로 간접적 주장이론을 본 사안에 적용하여 을이 변제사실을 주장한 것으로 볼 수 있을 것이다.

4. 결론

법원은 대여사실과 변제사실을 인정하여 갑의 청구를 기각하는 판결을 할 수 있다.

<사례문제 2의 해결>

1. 문제의 소재

피고가 원고의 청구를 배척시키기 위하여 소송법상 또는 실체법상의 이유를 들어 적극적인 방어를 하는 것을 널리 항변이라고 한다. 이에는 소송절차에 관한 항변인 소송상의 항변(실체법상의 효과에 관계 없는 항변)과 원고의 청구를 기각시키기 위한 목적의 실체관계에 관한 항변인 본안의 항변(실체법상의 효과에 관계있는 항변)이 있는

3) 대법원 2008.11.8. 선고 2008다39361 판결; 93.2.12. 선고 91다33384 판결.

데 설문은 본안의 항변과 간접부인의 구별기준과 그 차이점에 관하여 묻고 있다.

2. 본안의 항변과 부인의 개념 및 형태

(1) 본안의 항변이란 피고가 원고의 청구를 배척시키기 위하여 원고의 주장사실이 진실임을 전제로 하여 이와 양립 가능하며 자신에게 증명책임이 있는 별개의 요건사실에 대하여 하는 사실상의 진술을 말한다.

(2) 일반적으로 원고는 소를 제기하여 청구인용판결을 청구를 함에 있어서 그 청구원인 사실로서 자신의 권리를 발생시키는 원인이 되는 사실 즉 권리근거규정의 요건사실(권리발생사실)을 주장하게 되고, 이에 대하여 피고는 원고의 청구를 배척시키기 위하여 그 반대규정 즉 권리장애규정의 요건사실(권리장애사실) · 권리멸각규정의 요건사실(권리멸각사실) · 권리저지규정의 요건사실(권리저지사실)을 주장하게 되는데 이를 본안의 항변이라 한다.

(3) 부인이란 일반적으로 상대방이 증명책임을 부담하는 주장사실을 아니라고 부정하는 진술로서 이를 피고가 하는 경우에는 원고의 청구를 배척시키기 위하여 행하는 사실상의 진술이라는 점에서 항변과 차이가 없다. 그러나 항변은 원고의 주장사실이 진실임을 전제로 하여 이와 양립 가능한 별개의 요건사실을 주장하는 것이므로 그 답변태도가 “그렇다, 하지만”임에 대하여 부인은 원고의 주장사실이 아니라는 주장이므로 “아니다”인 점에서 차이가 있다.

(4) 피고가 하는 부인에는 원고의 주장사실이 진실이 아니라고 한마디로 부정하는데 그치는 직접부인(단순부인, 소극부인)과 원고의 주장사실과 양립되지 않는 별개의 사실을 적극적으로 진술하면서 원고의 주장사실을 부정하는 간접부인(이유부 부인, 적극부인)이 있는데, 실무상 항변과 간접부인과의 구별이 대단히 중요하게 취급된다.

2. 간접부인과 항변

(1) 양자의 구별기준

간접부인은 원고의 주장사실과 논리적으로 양립되지 않는(양립 불가능한) 별개의 사실을 진술하는 것임에 대하여, 항변은 원고의 주장사실이 진실임을 전제로 하여 그와 논리적으로 양립될 수 있는(양립 가능한) 별개의 사실을 진술하는 것임에 차이가 있다.

(2) 양자 구별의 필요성

1) 증명책임상의 차이점

증명책임분배의 원칙상 부인의 경우에는 부인당한 사실에 대한 증명책임이 그 상대방 즉, 원고에게 돌아가지만, 항변의 경우에는 항변사실의 증명책임이 그 항변 제출자인 피고에게 있다.

2) 판결이유에서의 판단(기재)요부

피고의 항변이 이유가 없어서 원고의 청구를 인용할 경우, 법원은 반드시 판결이유에서 피고의 항변을 배척하는 판단을 하여야 하고 이를 하지 않은 경우에는 판단누락의 위법이 있게 되지만, 간접부인 사실에 관하여는 이를 배척하는 판단이 필요하지 않다.

3) 청구원인 사실의 구체적 주장의 필요성

원고의 청구원인 사실이 피고로부터 부인 당한 경우에는 원고는 청구원인사실을 구체적으로 밝혀야할 부담(구체적 주장책임)이 따르지만 피고가 항변을 한 경우에는 원고에게 이와 같은 부담이 없다.

3. 사안의 해결

문1. (1)의 해결

1) 사안에서 무상으로 증여받았다는 을의 주장은 갑이 주장하는 매각(매매계약체결)사실과는 양립 불가능한 것으로서 간접부인에 해당한다. 따라서 무상으로 증여받았다는 사실이 진위불명 상태에 빠졌다 하더라도 이에 대한 증명책임이 을에게 있는 것이 아니라 갑은 을에 의하여 부인당한 매매계약 체결 사실을 증명하여야 한다(즉 매매계약 체결 사실에 대한 증명책임은 갑에게 있다). 그런데 증거조사의 결과 갑과 을 간의 매매계약 체결 사실이 인정되므로 법원은 그 사실이 존재하는 것으로 판단하여야 한다.

2) 한편 병의 대여금 채무 면제주장은 갑이 주장하는 금전 대여사실이 진실임을 전제로 그와 논리적으로 양립 가능한 주장이므로 항변에 해당한다. 따라서 병은 항변으로 주장된 면제사실에 관한 증명책임을 부담하는데 법원의 증거조사결과 갑과 병 간의 대여사실 만이 인정되고 면제사실은 진위불명 상태에 빠졌으므로 병은 그에 대한 증명책임을 부담한다. 따라서 법원은 면제사실은 존재하지 않는 것으로 판단하여야 한다.

문1.(2)의 해결

(1) 갑의 을과 병에 대한 청구에 관한 판결

법원은 갑과 을 간에 있어서 매매계약 체결 사실이 인정되므로 을에 대한 청구를 전부 인용하는 판결을 선고하여야 하고, 갑과 병 간에 있어서 대여사실이 인정되고 대여금채무에 대한 면제사실은 진위불명 상태에 빠지게 되어 그 사실은 존재하지 않는 것으로 취급하여 판결하여야 하므로 병에 대한 청구도 전부 인용하는 판결을 선고하여야 한다. 즉 법원은 갑의 을과 병에 대한 청구를 전부 인용하는 판결을 선고하여야 한다.

(2) 판결이유에서 실시하여야 할 사항

법원이 갑의 을에 대한 청구인용 판결을 선고함에 있어서 을이 주장한 무상증여사실은 간접부인으로서 법원이 매매계약 체결 사실이 인정된다고 판단함으로서 이미 피고의 간접부인(무상증여 사실)을 배척하는 판단을 한 것으로 볼 수 있으므로 판결이유에 무상증여 사실의 인정 여부에 관한 판단을 실시할 필요가 없고 매매계약 체결 사실이 인정됨을 실시하면 족하다.

반면에 법원이 갑의 병에 대한 청구인용 판결을 선고함에 있어서 병이 주장한 채무면제 사실은 항변에 해당하므로 판결이유에 대여사실이 인정됨을 실시 함과 아울러 반드시 병이 주장한 채무면제 사실이 인정되지 아니함을 실시하여야 한다. 만약 이를 실시(판단)하지 아니한 경우 그 판결에는 판단누락의 위법이 있게 되어 상소이유가 된다.

<사례문제 3에 대한 해결>

1. 문제의 소재

당사자가 소송절차 외에서 일단 형성권(해제권, 해지권, 취소권, 상계권)을 행사한 후 소송상 그 사법상의 효과를 진술하는 경우가 아니라 소송절차에서 비로소 형성권을 행사하면서 이를 공격방어방법으로서 주장하는 경우에 그에 따른 사법상(실체법상)의 효과가 어떻게 되는 것인지에 관하여 견해의 대립이 있다. 일반적으로 ① 소가 취하되거나 부적법 각하되는 경우 또는 ② 그 공격방어방법이 실기되어 각하되는 경우 ③ 사안에서와 같이 소송계속 중 수소법원의 조정(임의조정)이 성립되는 경우 등에 있어서, 특히 피고가 소송상 상계권을 행사하면서 상계항변을 했는데 위 ①, ②, ③과 같은 상황이 생긴 경우에 상계의 의사표시에 따른 사법상의 효과(반대채권소멸의 효과)가 잔존하는지의 여부에 관하여 논의가 있는데, 이는 그 법적 성질을 어떻게 볼 것인지에 따라 결론이 달라지게 된다.

2. 소송상 형성권의 행사의 법적 성질과 그에 따른 사법상의 효과

(1) 사법생위설(병존설)

외관상 하나의 행위이지만 법률적으로 볼 때 형성권의 행사라는 상대방에 대한 사법상의 의사표시(사법행위)와 그러한 의사표시가 있었다는 것을 법원에 대하여 사실상 진술(소송행위)하는 두 가지 행위가 병존한다고 보는 견해이다. 이에 의하면 위 ①, ②, ③의 경우에 형성권 행사에 따라 애당초 발생한 사법상의 효과가 그대로 존속되는 것으로 본다.

(2) 양성설

사법행위와 소송행위의 두 가지 성질을 모두 갖춘 하나의 행위인 것으로 보아 소송행위로서 소송법상의 효과가 생기지 않는 때에는 사법상의 효과도 생기지 않는다고 한다. 이에 의하면 위 ①, ②, ③의 경우에 형성권 행사에 따라 애당초 발생한 사법상의 효과는 소멸되는 것으로 본다.

(3) 소송행위설

형성권의 소송외의 행사와는 전혀 성질을 달리하는 소송상의 공격방어행위로서 소송법 고유의 소송행위인 것으로 보는 견해로서 이에 의하면 위 ①, ②, ③의 경우에는 애당초부터 아예 형성권 행사에 따라 사법상의 효과가 발생한 적이 없었던 것으로 취급된다.

(4) 신병존설

상계권을 제외한 형성권을 소송상 행사한 경우에는 병존설의 입장을 따르지만, 소송상 상계권을 행사한 경우(상계항변)에 있어서 만든 위 ①, ②, ③의 경우에 사법상의 효과(반대채권소멸의 효과)가 발생하지 않는 것으로 보는 견해이다. 즉 상계항변에 포함된 상계의 의사표시는 그 항변이 공격방어방법으로서 각하되거나 실효되지 않고 이것이 유효하게 취급되어 법원이 소구채권이나 반대채권의 존부등 상계항변에 관하여 판단한 경우에 한하여 그에 따른 사법상의 효과가 발생하는 것으로 보는 견해로서 현재 통설의 입장이다.

(4) 판례의 태도

대법원은 “원고가 소제기를 함으로써 계약해제권을 행사한 것으로 보여지는 경우, 해제권은 형성권이므로 비록 그 후에 원고가 소를 취하였다 하여도 위 해제권 행사의 효력에 아무런 영향도 미치지 아니한다”고 판시하고 있고,⁴⁾ 소송상 방어방법으로서 상계항변이 있었으나 소송절차 진행 중 조정이 성립됨으로써 수송채권의 존재에 관한 법원의 실질적인 판단이 이루어지지 않은 경우, 상계항변의 효과가 발생하는지 여부에 관하여 “소송상 방어방법으로서

4) 대법원 1982.5.11.선고 80다916판결

의 상계항변은 그 수동채권의 존재가 확정되는 것을 전제로 하여 행하여지는 일종의 예비적 항변으로서 당사자가 소송상 상계항변으로 달성하려는 목적, 상호양해에 의한 자주적 분쟁해결수단인 조정의 성격 등에 비추어 볼 때 당해 소송절차 진행 중 당사자 사이에 조정이 성립됨으로써 수동채권의 존재에 관한 법원의 실질적인 판단이 이루어지지 아니한 경우에는 그 소송절차에서 행하여진 소송상 상계항변의 사법상 효과도 발생하지 않는다고 봄이 상당하다"고 판시하고 있음과 아울러(대법원 2013. 3. 28. 선고 2011다3329 판결) "소송상 상계는 소송상 상계의 의사표시에 의하여 확정적으로 효력이 발생하는 것이 아니라 해당 소송에서 수동채권의 존재 등 상계에 관한 실질적 판단이 이루어지는 경우에 비로소 실제법상의 효과가 발생한다"고 판시하고 있는데(대법원 2014.6.12. 선고 2013다95964 판결), 이는 신병존설의 입장에 서 있는 것으로 평가된다.⁵⁾

(5) 소결

예컨대 원고의 매매대금청구의 소에 대하여 피고가 소송상 하자담보책임을 이유로 계약 해제 의사표시를 하면서(해제권을 행사하면서) 이를 방어방법으로 주장하였지만 원고가 소를 취하한 경우, 소송행위설이나 양성설에 의하면 소송이 판결에 의하지 않고 종료되었으므로 해제의 의사표시에 따른 사법상의 효과는 발생하지 않는 것이 된다(해제의 의사표시는 없었던 것으로 취급된다). ~~그런데~~ 원고가 장래에 다시 같은 소를 제기하여 온 경우에 피고는 하자담보책임을 이유로 해제권을 행사하려고 하여도 제척기간이 이미 경과됨으로써 이를 행사할 수 없게 ^{상황이} 생길 수 있다. 이에 반하여 사법행위설에 의하면 해제권 행사의 효과는 소의 취하에 의하여 상실되는 것이 아니므로 소송행위설이나 양성설에 의할 때와 같은 불합리한 결과가 생기는 않게 된다는 점에서 기본적으로 병존설의 입장이 타당하다고 생각된다. 그러나 다른 형성권과는 달리 피고가 상계권을 소송상 행사한 경우에 있어서도 병존설의 입장에 서게 되면 위 ①, ②, ③의 경우에 피고에게는 상계의 의사표시에 따른 반대채권 소멸의 효과가 그대로 잔존하는 결과 피고는 애당초 상계의 항변을 하지 않았던 것보다 더 불리한 지위에 놓이게 되는 불합리한 결과가 발생하게 된다는 점에서 이러한 문제를 피할 수 있는 신병존설의 입장이 타당한 것으로 생각된다.

3. 결론 - 법원의 갑의 항변에 대한 판단

(1) 을의 손해배상채권이 잔존하는지의 여부

신병존설 및 판례의 취지에 따를 경우 을이 전소에서 손해배상채권을 자동채권으로 하여 상계항변을 하였지만 전소가 임의조정으로 종료됨으로써 그 소구채권(공사대금채권)이나 반대채권(손해배상채권)의 존부 등 상계항변에 관한 법원의 실질적 판단이 이루어지지 않았다. 따

5) 2015.3.20. 선고 2012다107662 판결도 같은 취지이다..

라서 위 상계항변은 그 사법상 효과도 발생하지 않는다고 보아야 하므로 반대채권인 을의 손해배상채권은 소멸하지 않고 잔존하게 된다.

(2) 따라서 乙의 손해배상채권은 전소에서 상계권 행사에 의하여 소멸하였다고 주장 갑의 항변은 타당하지 않음으로 법원은 이를 배척하여야 한다.

(3) 더구나 을의 손해배상채권은 전소의 소송물이 아니었을 뿐만 아니라 그 조정조서의 조정조항에 특정되거나 청구의 표시 다음에 부가적으로 기재되지 아니하였으므로 특별한 사정이 없는 한 위 조정조서의 효력이 을의 손해배상채권에 미치지 않으므로 갑의 항변은 타당하지 않아 법원은 이를 배척하여야 한다

<사례문제 4의 해결>

문제1. (1)의 경우

1. 문제의 소재

설문은 합의서가 처분문서임을 전제로 그것이 진정하게 작성된 것임이 인정되는 경우 (형식적 증거력이 인정되는 경우) 특별한 사정이 없는 실질적 증거력도 인정된다는 전제하에 정지조건부로 소를 취하하기로 하는 내용의 합의서가 작성되었고 피고가 그 합의에 따른 의무를 이행하여 그 조건이 성취되었음에도 불구하고 원고가 그 합의에 반하여 소취하를 하지 않고 있는 경우, 법원은 어떤 판결을 선고하여야 하는지를 묻고 있다. 이는 소취하 합의의 성질을 어떻게 파악할 것인지에 따라 결론이 달라질 것이다.

2. 소취하 합의(계약)의 의의 및 법적 성질

(1) 소취하 합의는 소송상 합의의 일종으로서 소송 외에서 원고가 피고에 대한 소를 취하하기로 하는 내용의 원고, 피고 간의 약정을 말하는데, 법규에 이를 허용하는 명문 규정은 없더라도 소송에서 있어 당사자의 처분의 자유가 인정되는 영역 즉 처분권주의와 변론주의가 적용되는 영역에서는 그 유효성을 인정하는 것이 일반적이다. 그런데 그 법적 성질과 그에 위반된 행위의 효력에 관하여는 논의가 있다.

(2) 성질

1) 사법계약설

소송행위의 개념을 좁게 파악하는 요건 · 효과설의 입장에서 소취하 합의는 '소를 취하하여야 한다'는 사법상의 의무를 발생시키는 사법계약이라고 한다. 만약 원고가 이를 위반하여 소송을 계속 유지하는 경우 ① 피고는 그에 대응하여 의무이행을 소구

하거나 손해배상을 청구할 수 있다는 입장(의무이행소구설)과 ② 의무이행의 소구나 손해배상청구는 우회적인 방법이므로 피고에게 당해 소송에서 항변권이라는 구제수단을 부여하여 피고가 원고의 소취하 합의 위반 사실을 항변으로 주장·증명하면 법원은 권리보호 이익의 흠결을 이유로 소 각하 판결을 하여야 한다고 입장(항변권 발생설)이 있는데 후자가 다수설과 판례의 입장이다.⁶⁾

2) 소송계약설

소송행위의 개념을 넓게 파악하는 효과설의 입장에서 소취하 합의는 소송계속의 소멸이라는 소송법상의 효과를 발생시키는 소송행위(소송계약)라고 한다. 이에 ① 당사자의 주장을 통해 법원에 그 합의 사실이 알려지면 소송계속 소멸의 효과가 발생하므로 법원은 확인적 의미에서 소가 종료되었다는 소송종료선언판결을 하여야 한다는 입장(순수 소송효과설)과 ② 소취하 합의에는 소송계속의 소멸이라는 효과 뿐 만 아니라 의무부과적 효과까지도 발생하므로 그 합의 위반자를 상대로 손해배상도 청구할 수 있다는 입장이 있다(발전적 소송계약설).

3) 소결

의무이행소구설은 피고에 대한 구제방법이 우회적이고 간접적이라는 점, 소송계약설에 의하면 소송 외에서 행한 소취하 합의와 소취하를 그 방식이나 효과면에서 동일하게 취급하게 된다는 점에서 문제가 있으므로 항변권발생설이 타당한 것으로 생각된다.

3. 결론 ; 사안에의 적용

법원이 법원이 심리를 종결한 결과 을이 소취하 합의가 있었음을 주장(항변)하면서 증거로 제출한 합의서(처분문서)가 진정하게 작성된 사실이 인정되므로 특별한 사정이 없는 한 그 내용(조건부 소취하 합의사실)은 인정되어야 한다. 한편 을이 갑에게 200만 원을 지급한 사실이 인정됨으로써(조건이 성취됨으로써) 효력이 발생된(유효한 상태의) 소취하 합의가 존재함에도 불구하고 갑이 그에 위반하여 소를 유지하고 있으므로 을의 항변은 이유있고 증명된 것으로 보아야 한다. 따라서 법원은 항변권발생설에 따라 법원은 갑의 소에 대해 권리보호의 이익이 없다는 이유로 소각하 판결을 하여야 할 것이다.⁷⁾

6) 2005.6.10. 선고 2005다14861; 1982.3.9. 선고 81다1312 판결 등

7) 만약 법원이 소송계약설을 따른다면 '이 사건 소송은 모년 모월 모일..자 소취하 합의에 의하여 종료되었음을 선언한다는 소송종료선언을 하여야 할 것이다.'

문제1.(2)의 경우

1. 문제의 소재

본안에 관한 종국판결선고 후에 소를 취하한 자는 이미 취하한 소와 동일한 소를 재차 제기하는 것이 금지되는 제재를 받게 되는데 이를 재소금지의 원칙이라 한다. 이 원칙이 적용되기 위하여는 ① 전소와 후소의 당사자가 동일할 것 ② 전소와 후소의 소송물이 동일할 것 ③ 본안에 관한 종국판결선고 후에 소가 취하되었을 것 ④ 전소와 후소의 권리보호이익이 동일한 것이 요구되는데, 본 사안은 위 ①과 ④의 요건과 관련되어 문제 된다. 즉 ①의 요건과 관련하여 항소심에서 소를 취하한 갑으로부터 취하된 전소의 소송물인 권리관계를 그대로 양도받은 병이 특정승계인으로서 갑과 동일하게 재소금지의 효과를 받는 당사자가 되는지의 여부와 ④의 요건과 관련하여 피고인 을이 소취하의 전제조건을 위반한 경우 즉 합의금을 지급하겠다는 을의 말을 믿고 갑이 소를 취하했는데 을이 그 약속을 이행하지 않음으로써 갑 또는 그 특정승계인 병이 다시 소를 제기하는 경우, 이는 전소와는 권리보호의 이익이 다른 것이므로 재소금지 원칙은 그 적용이 없는 것으로 보아야 하는 것인지의 여부가 문제된다.

2. 재소금지의 효력이 특정승계인 병에게도 미치는지의 여부

(1) 견해의 대립

재소금지의 효력이 당사자인 원고나 그의 변론종결 후의 일반승계인(포괄승계인)에게 미친다는 점에는 이론이 없으나 변론종결 후의 특정승계인에게도⁸⁾ 미치는가에 대해서는 논의가 있다.

① 부정설

재소금지의 효력은 기판력과 같이 법적 안정성을 위한 것이 아니고 소권남용에 대한 제재이므로 전소의 취하를 알면서 승계했다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특정승계인에게는 그 효력이 미치지 않는다는 입장이다.

② 긍정설

원고가 본안에 관한 종국판결을 받은 이상 절차보장이 되었다고 보아야 하기 때문에 그 특정승계인에게도 그 효력이 미치는 것으로 보아야 한다는 견해인데, 판례는 기본적으로 후자의 입장이지만, 재소금지의 효력을 받는 특정승계인이라도 그에게 다시 소를 제기할 권리보호이익이 있는 때에는 재소를 허용한다.⁹⁾

8) 여기서 특정승계인이라 함은 변론종결 후에 원고로부터 전소의 소송물인 권리관계 또는 계쟁물을 양수함으로써 소송물에 관한 당사자적격을 취득한 제3자를 의미한다.

9) 대법원 1981.7.14.선고 81다64 판결

④ 소결

생각건대 판례와 같이 원칙적으로 특정승계인에게도 재소금지의 효력이 미치는 것으로 보되 피고가 소취하의 전제조건을 위반한 경우 등과 같이 원고나 그 승계인에게 다시 소를 제기할 사정변경이 생기거나 새로운 권리보호이익이 생긴 때에는 재소를 제기할 수 있는 것으로 보는 것이 타당할 것이다.

3. 권리보호의 이익이 동일한지의 여부

재소의 권리보호의 이익과 취하한 전소의 권리보호의 이익이 서로 다를 때에는 재소금지의 원칙이 적용되지 않는다. 재소금지의 효력은 소취하의 남용과 재소의 남용을 금지하기 위한 것으로 소권을 박탈하는 제도는 아니기 때문이다. 따라서 예컨대 피고가 소취하의 전제조건인 약정사항을 이행하지 않아 그 약정이 실효되는 등의 사정변경이 생김으로써 원고가 다시 제기하는 소는 전소와는 권리보호이익을 달리 하는 것으로서 당연히 허용되어야 한다.

4. 사안의 해결

갑의 소취하는 본안에 관한 종국판결 선고 후인 항소심에서 행해졌으므로 갑은 재소금지의 효력을 받게 되고 원칙적으로 갑의 특정승계인인 병에게도 그 효력이 미치는 것으로 보아야 한다. 그러나 사안의 경우, 갑이 소취하를 하였음에도 을은 소취하의 전제조건이었던 갑과의 합의금 지급 약속을 이행하지 않음으로써 갑에게는 새로운 사정변경이 생긴 것으로 보아야 하고, 이에 원고가 재소를 제기하더라도 이는 취하된 전소와는 권리보호이익을 달리하는 것으로서 재소금지의 원칙의 적용대상이 되지 않는다. 이와 같이 재소금지의 제재를 받지 않고 다시 소를 제기할 수 있는 상태에 있던 갑으로부터 전소의 소송물인 권리관계를 양도받은 특정승계인 병에게도 재소금지의 원칙의 적용되지 않는다고 하여야 하므로 병이 제기한 소는 적법한 것으로 보아야 한다.